DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 21-2022-DTD-CECARD/ARBITRAJE DE EMERGENCIA/ AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje de Emergencia.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio Nazareno.

Demandado : Municipalidad Distrital de Vinchos.

ARBITRO DE EMERGENCIA : Abg. Daniel Triveño Daza.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

PEDIDO CAUTELAR : Medida Cautelar de No Innovar

INICIO DE LA SOLICITUD : 02 de diciembre de 2022.

FECHA DE CONCLUSION : 12 de diciembre de 2022.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

CONSORCIO NAZARENO vs. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS

DECISIÓN N° 3 – CUADERNO CAUTELAR

Lima, 12 de diciembre de 2022

I. ANTECEDENTES:

1.1. El escrito presentado por el Consorcio Nazareno (en adelante, Consorcio) el 02 de diciembre de 2022, bajo la sumilla: *"Solicitamos arbitraje de emergencia y pedimos tutela cautelar".*
1.2. La Decisión N^{0}1 – CUADERNO CAUTELAR del 02 de diciembre de 2022.
1.3. El escrito presentado por el Consorcio el 05 de diciembre de 2022 bajo la sumilla: *"Solicito corrección de error material".*
1.4. La Decisión N^{0}2 – CUADERNO CUATELAR del 05 de diciembre de 2022.
1.5. El escrito presentado por el Consorcio el 07 de diciembre de 2022 bajo la sumilla: *"Presento constancia de pagos de honorario de árbitro de emergencia y gastos administrativos".*

II. ANÁLISIS:

1. Mediante la Decisión N° 1, entre otros, se corrió traslado a la Entidad del pedido cautelar de no innovar solicitado por el Consorcio para que en un plazo reglamentario de (2) dos días hábiles, exprese lo conveniente a su derecho.

2. En ese sentido, y mediante la presente, se deja constancia que la Entidad no absolvió el traslado conferido mediante Decisión N° 1, conforme a lo señalado en el mencionado escrito.

3. Por lo que, este Árbitro de Emergencia, y verificados los pagos por honorarios conforme al escrito de antecedentes (1.5), procederá a resolver el pedido cautelar de no innovar presentado por el Consorcio, sin la absolución de la contraparte, conforme al numeral 5 del artículo 3º del Reglamento de Árbitro de Emergencia del Centro de Arbitraje CECARD.

4. En efecto, mediante el escrito de antecedentes (1.1), el Consorcio solicitó se le otorgue una **medida cautelar de no innovar,** a fin de que:

   "1. Que la Municipalidad Distrital de Vinchos se abstenga de ejecutar la Carta Fianza No. 3002020016728-4, emitida por AVLA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A por el importe de S/. 1´379,586.95 (Un Millón Trescientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Seis con 95/100 soles) que garantiza el fiel cumplimiento del Contrato No. 466-2020-MDV/GM-UA.

   2. Que AVLA Perú Compañía de Seguros S.A, se abstenga y/o rechace cualquier requerimiento y/o solicitud por parte de la Municipalidad Distrital de Vinchos destinada a ejecutar la Carta Fianza No. 3002020016728-4".

5. Ahora bien, el Consorcio, sustenta su posición en base a la siguiente argumentación:

5.1 El Consorcio, en cuanto a la competencia del Árbitro de emergencia señala lo siguiente:

- El Art. 63° del Reglamento del Centro de Arbitraje – CECARD, establece lo siguiente:

  "(…) Artículo 63º.- Medida cautelar emitida por Árbitro de Emergencia
  1. Hasta antes de la constitución del Tribunal Arbitral, cualquiera de las partes que requiera medida cautelar urgente puede solicitar que se inicie un procedimiento ante un árbitro de emergencia, quien conoce y resuelve la respectiva solicitud.
  2. Las decisiones adoptadas por el Árbitro de Emergencia son vinculantes para las partes, quienes, por el hecho de haber sometido la controversia a arbitraje bajo el Reglamento, se obligan a cumplirlas sin demora. (…)"

5.2 Sobre la medida cautelar, en cuanto a la **verosimilitud del derecho invocado**, señala lo siguiente:

Sobre la resolución del Contrato

- El Consorcio señala que con fecha 02 de diciembre de 2020, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS y el CONSORCIO NAZARENO suscribieron el Contrato No. 446-2020-MDV/GM-UA para la Ejecución de la Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN 16 LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNIDAD DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS – HUAMANGA – AYACUCHO", derivada de la Adjudicación Simplificada DU114-2020-No. 001-2020-MDV/CS (Primera Convocatoria). Siendo el plazo de ejecución de 300 días calendarios.

- Asimismo, el Consorcio señala que conforme al asiento 726 del Cuaderno de Obra de fecha 19 de mayo de 2022, se tiene la anotación del Residente de Obra, en la cual señala la culminación de la Obra. Y que en el asiento 727 de fecha 19 de mayo de 2022 el Supervisor de Obra señala que se procede a verificar la culminación de la obra, y que en el asiento 728 de fecha 24 de mayo de 2022 señala que se han culminado con las metas, de acuerdo con el contrato principal y los adicionales. Conforme a ello el Consorcio precisa que correspondía, conforme al artículo 208º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que se proceda con la designación del comité de recepción y consecuentemente con la verificación de la obra, hecho que según el Consorcio no se efectuó dada la resolución del contrato.

- El Consorcio precisa que con fecha 15 de setiembre de 2022, la Entidad comunicó al Consorcio la **resolución del Contrato**, mediante Carta Notarial No. 015-2022/MDV. **Siendo la causal de resolución la aparente acumulación máxima de penalidades.**

- En postura del Consorcio es imposible que una vez culminada la obra se pueda incurrir en penalidades y, por lo tanto, tampoco se podría incurrir en aplicación máxima de penalidades, dado que la Entidad no habría designación al Comité de Recepción de Obra, y por lo tanto no se habrían realizado las observaciones del caso ni otorgado un plazo para subsanarlas.

Sobre el procedimiento de liquidación de obra

- En ese sentido, continúa el Consorcio, conforme al artículo 207º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (aprobado mediante DS No. 344-2018-EF), y ante la resolución del contrato, debe seguirse con la liquidación de la obra y que esto no es solo un criterio legal sino también un criterio lógico de que, resuelto el contrato (esto es, finalizado el vínculo contractual) se deba de proceder con la liquidación de la obra, en la cual se reflejarán los gastos realizados y los saldos que existan a favor o en contra del Contratista o de la Entidad.

- Entonces, continúa el Consorcio, se tiene que en la liquidación de obra se pondrá por un lado el costo total de la obra (hasta el momento de la resolución del contrato) y la existencia de saldo (o pagos) a favor o en contra del Contratista o de la Entidad, esto, con la finalidad de determinar el estado financiero de la obra.

Sobre la vigencia de la carta fianza y la liquidación de la obra

- Lo expuesto, continúa el Consorcio, se encuentra estrechamente relacionado con la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento, de adelanto directo y de adelanto de materiales; pues, de existir saldo en contra del Consorcio (como, por ejemplo, la amortización de los adelantos, o el pago de penalidades), es natural que esto sea solventado por las garantías correspondientes. A contrario sensu, si existe un saldo a favor del Consorcio, es también natural que las garantías sean devueltas; y, además, es más que notorio que estas garantías deben mantenerse vigentes hasta la liquidación de la obra, esto es, hasta que se dilucide la existencia de un saldo a favor o en contra del Contratista o de la Entidad.

- Por tanto, señala el Consorcio que, es necesario determinar la naturaleza de la Carta Fianza No. 3002020016728-4 que se pretende ejecutar. En ese sentido, como se señala en el artículo 126º del RLCE, la carta fianza que garantiza el fiel cumplimiento del contrato debe mantenerse vigente hasta la liquidación de obra. Esto, porque la finalidad de la liquidación de obra es precisamente *"determinar –principalmente– el costo total de la obra y la existencia de un saldo a favor o en contra del contratista o de la Entidad".*

- En ese sentido, continúa el Consorcio, el Consorcio tiene o saldos a su favor o deudas que aún no fueron pagadas por la Entidad, por lo que, en una futura

liquidación de la obra le corresponderá el pago de reajustes, que asciende a la suma de S/. 627,830.01 (Seiscientos Veintisiete Mil Ochocientos Treinta con 01/100 Soles). Entonces, la Carta Fianza No. 3002020016728-4 que garantiza el fiel cumplimiento del Contrato, debe ser mantenida hasta la realización de la liquidación de obra.

- Asimismo, continúa el Consorcio, siendo que la garantía de fiel cumplimiento tiene una finalidad que se encuentra estrechamente relacionada con la finalidad de la liquidación de obra, no se podría ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, si aun no se ha determinado los saldos existentes, a favor o en contra de la Entidad o del Contratista, lo que se efectúa con la realización de la obra, conforme al numeral 149.1 del artículo 149º del RLCE.

- Entonces, precisa el Consorcio, es necesario la realización de la liquidación de obra, y; por lo tanto, también es necesario que la Carta Fianza No. 3002020016728-4 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato se mantenga vigente hasta la realización de la Liquidación de Obra.

- En ese sentido, precisa el Consorcio, consideramos que nuestro derecho es verosímil pues se encuentra pendiente una liquidación de obra que contiene saldo a favor del Consorcio Nazareno y además las penalidades imputadas son jurídicamente inexistentes.

5.3 Ahora bien, en cuanto al **peligro en la demora**, el Consorcio señala la configuración de un perjuicio irreparable y además inminente que en el presente caso es concreto, pues de conformidad con la Carta Notarial S/N de fecha 30 de noviembre de 2022, en la que la Municipalidad Distrital de Vinchos requiere a AVLA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, la ejecución de la Carta Fianza No. 3002020016728-4; y siendo esta fianza incondicional, es inminente su ejecución.

5.4 Por otro lado, en cuanto a la **proporcionalidad y adecuación**, el Consorcio señala que la medida cautelar de no innovar tiene como objeto mantener la situación de hecho y de derecho de la Carta Fianza No. 3002020016728-4 que garantizo el fiel cumplimiento del Contrato No. 466-2020-MDV/GM-UA mediante su no ejecución. Siendo la medida cautelar de no innovar la más adecuada para dichos efectos.

5.5 En relación a la **contracautela**, el Consorcio ha precisado que ofrece como contracautela una Caución Juratoria de cuantía indeterminada, asimismo sobre el DU 20-2020 que modifica el numeral 2 del artículo 8º de la Ley de Arbitraje y que en los casos en los que el Estado peruano es parte solicita la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad pública, **el Consorcio solicita la inaplicación de tal normativa**, precisando que el Árbitro de Emergencia deberá tener en consideración que la solicitud de medida cautelar se realiza en ejercicio de su derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, que se encuentra reconocida en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política vigente, y que dicho derecho debe prevalecer por sobre una traba ilegal tal como la establecida por el DU 20-2020. Y que por estas razones, al vulnerarse derechos constitucionales tales como el de igualdad y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, solicitan al Árbitro de

Emergencia que, en el marco del reconocimiento establecido en el precedente vinculante por el Tribunal Constitucional en el Exp. 142-2011-PA/TC, efectuar el control difuso y establecer que no corresponde exigir para el caso concreto la fianza bancaria y/o patrimonial señalada en la norma que se inaplica (modificatoria al numeral 2 del artículo 8° de la Ley de Arbitraje por medio del DU 20-2020).

6. Por su parte, y como se preciso en la parte de antecedentes, la Entidad no cumplió con absolver el traslado conferido mediante la Decisión No. 1.

7. Ahora bien, este Árbitro de Emergencia considera pertinente establecer el marco legal sobre el cual se analizará la solicitud cautelar de no innovar planteada por el Consorcio.

SOBRE LA SOLICITUD CAUTELAR DE NO INNOVAR

8. Al respecto, previo a analizar la medida cautelar planteada por el Consorcio, cabe establecer la norma aplicable para analizar el fondo de la controversia.

9. Sobre el particular, cabe señalar que la norma aplicable al presente es la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante D.S N° 082-2019-EF (en adelante, la LCE) y su Reglamento aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF y sus modificaciones (en adelante, el RLCE), ello en atención a la fecha de convocatoria del Proceso de Selección. En caso de vacío se aplicará el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.

10. Aclarado lo anterior, corresponde verificar el convenio arbitral establecido por las partes. Sobre el particular, la cláusula décimo novena del Contrato No. 446-2020-MDV/GM-UA para la Ejecución de la Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN 16 LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNIDAD DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS – HUAMANGA – AYACUCHO"
(en adelante, el Contrato), establece lo siguiente:

> **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**
> Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
> Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
> Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

11. De lo anterior, se observa que las partes han establecido que las controversias se resuelven mediante conciliación o arbitraje, teniendo el derecho cualquiera de las partes de iniciar el arbitraje conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

12. Ahora bien, este Árbitro de Emergencia verifica que en dicha cláusula no se ha establecido ni el tipo de arbitraje ni el Centro de Arbitraje ante el cual las partes deben iniciar el arbitraje.

13. En ese sentido, corresponde verificar que establece la Ley de Contrataciones y su Reglamento sobre el particular, a fin de confirmar la competencia del presente Árbitro de Emergencia para resolver las cuestiones traídas a resolver.

14. Sobre el particular, el Art.226.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece lo siguiente:

    "(…)
    226.2 En los siguientes supuestos, ***el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral****:*
    (…)
    d) ***Cuando en el convenio arbitral no se haya precisado el tipo de arbitraje.***
    (…)" (el subrayado y resaltado es nuestro)

15. De lo anterior, se verifica que la norma faculta a la parte que inicia el arbitraje, el decidir la institución arbitral que considere pertinente para iniciar el proceso arbitral cuando no se haya establecido el tipo de arbitraje, conforme sucede en el presente caso.

16. En atención a ello, de acuerdo a lo informado por el Contratista en su solicitud cautelar, siendo que este iniciará las controversias sobre la ineficacia de la resolución del contrato y el reconocimiento del pago de reajustes contenidos en las valorizaciones de junio de 2021 a enero de 2022, la norma aplicable lo faculta para elegir cualquier institución arbitral, siendo esta institución arbitral el CECARD.

17. Ahora bien, dentro del Reglamento del Centro de Arbitraje CECARD, se observa que el mismo regula la figura del Árbitro de Emergencia en su Art.63, estableciendo lo siguiente:

    "(…) Artículo 63º.- Medida cautelar emitida por Árbitro de Emergencia
    1. Hasta antes de la constitución del Tribunal Arbitral, cualquiera de las partes que requiera medida cautelar urgente puede solicitar que se inicie un procedimiento ante un árbitro de emergencia, quien conoce y resuelve la respectiva solicitud.
    2. Las decisiones adoptadas por el Árbitro de Emergencia son vinculantes para las partes, quienes, por el hecho de haber sometido la controversia a arbitraje bajo el Reglamento, se obligan a cumplirlas sin demora. (…)"

18. En ese sentido, se tiene clara la competencia del presente Árbitro de Emergencia para conocer la presente controversia.

19. A mayor sustento, se debe tener en cuenta que la medida cautelar es un pronunciamiento de carácter temporal que obliga a hacer o no hacer algo con la finalidad de proteger el resultado de una litis, pues debido a la demora en la resolución del conflicto, puede ocasionarse la pérdida o deterioro del derecho reclamado, con lo cual la ejecución de un eventual resultado favorable podría verse menoscabado con la pérdida de tal derecho.

20. Alberto Hinostroza señala que la medida cautelar es aquella institución procesal, mediante la cual el órgano jurisdiccional, a instancia de parte, asegura la eficacia o el cumplimiento de la sentencia a dictarse en el proceso que dirige, anticipando todos o determinados efectos del fallo[1]. De igual modo, para Monroy *"(…) el periculum in mora es la constatación que hace el Juez, que, si no concede la medida cautelar, puede que el fallo definitivo llegue a ser ilusorio o inejecutable. En tal sentido, debe haber una amenaza que ponga en riesgo la efectividad del fallo"*[2]

21. Asimismo, el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, en su artículo 47° regula las medidas cautelares como:

> *"**Artículo 47°. - Medidas Cautelares:***
> *(…) 2. Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, contenida en una decisión que tenga o no forma de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la emisión del laudo que resuelve definitivamente la controversia, el tribunal ordena a una de las partes:*
>
> *a. Que mantenga o restablezca el status quo en espera de que se resuelva la controversia;*
> ***b. <u>Que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del proceso arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al proceso arbitral;</u>***
> *c. Que proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo subsiguiente; o*
> *d. Que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia." (Lo subrayado y resaltado es agregado).*

22. En ese contexto, es de apreciar que la Ley de Arbitraje establece claramente que en sede arbitral se pueden dictar medidas cautelares, otorgando a los árbitros las facultades para conceder o no las mismas.

23. En atención a lo señalado, no cabe duda que, el Árbitro de Emergencia cuenta con las facultades necesarias para dictar medidas cautelares conforme al dispositivo legal anteriormente citado, por lo que, en virtud de ello, este Árbitro cuenta con competencia para emitir el pronunciamiento respectivo.

24. Aclarado ello, corresponde pasar a analizar la procedencia de la solicitud cautelar. Al respecto, es de advertir que la Ley de Arbitraje no especifica los presupuestos necesarios para el otorgamiento de una medida cautelar, por lo que es necesario recurrir a las prácticas arbitrales para poder determinar cuáles son dichos presupuestos, y a la luz de los mismos, analizar si el pedido de medida cautelar de no innovar presentado por el Contratista cumple con ellos o no.

---

[1] HINOSTROZA MINGUÉZ, Alberto. El embargo y otras medidas cautelares. Editorial San Marcos, 2da edición. Lima, 2000. Pág. 13.

[2] Citado por SIMONS, Adrián. Medidas cautelares especiales y poder general de cautela. En: Revista Advocatus. Universidad de Lima. Nº 7. Diciembre de 2002. Pág. 161.

25. Al respecto, en el ámbito internacional se reconoce como presupuestos para conceder una medida cautelar los siguientes: i) se tenga la certeza del derecho o "fumus bonis iure"; ii) que exista un peligro de daño sobre el derecho reclamado por la demora, iii) que exista una adecuación o razonabilidad de la medida cautelar, y; iv) una contracautela que garantice los posibles daños que pudiera ocasionar a la contraparte con el otorgamiento de la medida cautelar[3].

26. Asimismo, el Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente al presente proceso, establece lo siguiente:

    "Artículo 611.- Contenido de la decisión cautelar
    El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante, aprecie:
    1.- La verosimilitud del derecho invocado.
    2.- La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable.
    3.- La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión.
    (…)".

27. En ese sentido, este Árbitro concluye que, de acuerdo con las prácticas arbitrales tanto internacionales como nacionales y a lo establecido en el Art. 611º del CPC, los requisitos para solicitar una medida cautelar son: i) la verosimilitud del derecho; ii) peligro en la demora, iii) adecuación de la medida cautelar o razonabilidad de la medida cautelar y; iv) la contracautela.

28. Sobre los presupuestos de la medida cautelar, la verosimilitud del derecho invocado por el juez peruano Marte Chang señala lo siguiente; *"la realización de un juicio de probabilidad, provisional e indiciario a favor del accionante, no exige comprobación de certeza, sino solamente de humo de derecho, esto es, de probabilidad".*[4]

29. En ese sentido, la verosimilitud del derecho invocado no supone **un convencimiento total o cierto del juzgador respecto a las alegaciones**, sino solo una apariencia de verdadero (fumus boni iuris), **una hipótesis razonable que no se puede considerar prima facie como un pedido ajeno a derecho** y que estará sujeta a un examen y decisión posterior que podría inclusive ser al momento de la emisión del laudo.

30. Asimismo, y por ello, es preciso señalar que, por la naturaleza misma de la apariencia de verdadero (fumus boni iuris), no puede exigírsele al Árbitro de Emergencia sustentar su postura a favor o en contra del otorgamiento de la cautelar, en lo que respecta a la verosimilitud del derecho, sobre aspectos que serán dirimidos en el proceso principal, bajo pena de significar un adelanto de opinión. ***Es por ello que el Árbitro de Emergencia no necesita más que una apariencia del derecho y no una convicción plena, sino tan solo una mera hipótesis razonable.***

---

[3] BERGER, K.P. International economic arbitration. Kluwer. Deventer: 1993 Págs. 331-351.

[4] MARTEL CHANG, Rolando A. *Tutela Cautelar y medidas autosatisfactivas en el proceso civil.* Lima, Palestra Editores, 2003, p. 59

31. Por otro lado, respecto al peligro en la demora la doctrina a través del autor Ezequiel Cassagne nos menciona que:

> *"Es el peligro en la demora de la sentencia definitiva que se dictará en el proceso, o como dicen GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, "la urgencia para evitar que la demora en la resolución del pleito principal cause perjuicios apreciables" Se requiere que sobrevenga un perjuicio o daño inminente que transformará en tardío el eventual reconocimiento del derecho invocado como fundamento de la pretensión"*[5].

32. Por su parte el doctor Enrique Palacios Pareja, nos menciona que:

> *"Ahora bien, el derecho no solo tiene que encontrarse en una situación de riesgo, es imprescindible que dicho riesgo radique en la demora que el proceso supone, ya que de otra forma la medida cautelar no será el medio idóneo para reducir dicho riesgo. Por ejemplo, el embargo para evitar que durante el transcurso del proceso el deudor demandado disponga de su patrimonio haciendo ilusorio el derecho de crédito del acreedor demandante; o la suspensión de los efectos de una resolución administrativa impugnada judicialmente, que dispuso la clausura de un negocio, evitando así que mientras dure el proceso judicial se mantenga cerrado el negocio, con los graves perjuicios que ello ocasiona"*[6].

33. En ese sentido, la configuración del ***periculum in mora*** se produce cuando de la constatación razonable **de los hechos se evidencia que, si el juzgador no concede la medida cautelar solicitada en el momento pedido, no podrá hacerlo en el futuro, debido a que por la demora en el proceso el daño podría convertirse en irreparable** o; que el fundado temor en la espera de la tutela efectiva, lleguen a fallar o alterar las circunstancias de hecho favorables a la tutela misma.

34. De ahí que, el peligro en la demora **debe ser apreciado con relación a la urgencia en obtener protección especial**, dado los hechos indicativos de la irreparabilidad o el grave daño que puede significar esperar al dictado de sentencia, buscándose con este tipo de pedidos garantizar los efectos del ulterior fallo sino cautelar el ***statu quo*** hasta el fallo definitivo.

35. Por otro lado, respecto a la **adecuación o razonabilidad** de la medida cautelar, Jorge Antonio Plasencia Cruz[7] señala que el presupuesto de adecuación exige que el Juez deba ponderar la medida cautelar solicitada a aquello que se pretende asegurar,

---

[5] Cassagne, E. *"Medidas cautelares contra la administración".* Pág. 11 Recuperado el 17 de abril de 2018 de:http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/Las_medidas_cautelares_contra_la_Administracion,_en_Tratado_de_Derecho_Procesal_Adminsitrativo,_Director_Juan_Carlos_Cassagne,.pdf

[6] Palacios Pareja, E. (s.f.). Reflexiones sobre la caducidad de las medidas cautelares. En *Revista Ius Et Veritas 29* (págs. 23-31). Lima. Recuperado el 17 de abril de 2018 de: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSjoeou8LaAhXC3VMKHS4IACoQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Frevistas.pucp.edu.pe%2Findex.php%2Fiusetveritas%2Farticle%2Fdownload%2F11531%2F12051&usg=AOvVaw1nSpsdmR7IVkPw2YmDRiBg

[7] Plascencia Cruz, Jorge. La Buena Fe en el Proceso Cautelar; Derecho y Cambio Social. https://www.derechoycambiosocial.com/revista013/buena%20fe%20en%20el%20proceso%20cautelar.htm

debiendo dictar la medida que de menor modo afecte a los bienes o derechos de la parte demandada o, en todo caso, dictar la medida que resulte proporcional con el fin que se persigue.

36. En ese sentido, **debe señalarse que la medida cautelar debe ser proporcionada y evitar causar perjuicio a la contraparte**, lo que a su vez guarda relación con la contracautela.

37. Finalmente, la **contracautela**, como expresa el doctor Mariano Peláez Bardales[8], nos menciona que:

> *"Ronal Arazá, en su obra Medidas Cautelares, refiere respecto de la contracautela que esta* ***se funda en el principio de igualdad, en razón de que persigue el equilibro entre las partes****; por un lado, se autoriza al peticionario a asegurar un derecho aún no reconocido judicialmente, pero por otro se garantiza a éste la efectividad del resarcimiento por los daños y perjuicios que pudiere ocasionarle, si aquel derecho no existiera. (…)*
>
> *(…)* ***La contracautela se funda en el principio de igualdad y reemplaza en cierta medida a la bilateralidad o controversia asegurando al demandado frente al actor con una pretensión discutida o insatisfecha, la posibilidad de resarcirse los daños si esa pretensión no existiera o no llegare a actualizarse****, es, para quien pide la medida cautelar, una seguridad en caso de habérsela solicito mal".* (El resaltado y subrayado es nuestro).

38. Ante ello, este Árbitro de Emergencia considera que si bien la tutela cautelar busca proteger al accionante en aquel posible futuro derecho que le asista y que se demuestre en el proceso principal, lo cierto es que también es importante no dejar desprotegido al demandado, en este caso la Entidad, debiendo tomarse todas las precauciones a fin de que pueda ser indemnizado por los posibles daños que genere la admisión de una medida cautelar de esta naturaleza.

39. En ese sentido, lo que corresponde verificar es si esta solicitud cumple con los presupuestos señalados anteriormente.

RESPECTO DE LA VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO:

40. En primer lugar, se debe verificar si existe una apariencia del derecho conforme ha argumentado el Consorcio, por regla general la comprobación o prueba plena de la existencia de un derecho no solamente requiere de la instrucción suficientemente extensa para formar convicción –certeza– al árbitro, sino que exige el contradictorio, es decir, la asistencia o posibilidad de hacerlo de ambos sujetos con interés en el litigio.

41. En las medidas cautelares, conforme al interés que las justifica: el temor de la frustración o su urgencia, exigen suprimir o disminuir la instrucción y demorar la partición de uno de los interesados hasta que se hayan cumplido. De allí que la comprobación de la

[8] Peláez Bardales, M. (s.f.). *El Proceso Cautelar 2° Edicion.* Lima: Grijley. Pág. 44

existencia del derecho se haga en forma sumaria –cognición sumaria–, de manera que proporcione la verosimilitud de derecho[9]. Por eso, la adopción de la medida cautelar no debe depender de que el actor pruebe la existencia del derecho subjetivo por él alegado en el proceso principal, ya que esa existencia es la que se debate en éste, pero tampoco puede adoptarse la medida cautelar sólo porque lo pida el actor, en uno y otro extremo la adopción precisa que se acrediten unos indicios de probabilidad, verosimilitud de apariencia del buen derecho[10] . Al respecto, el autor PODETTI refiere «El interés privado y público de asegurar la oportuna y eficaz actuación de un derecho, permite prescindir, provisionalmente, de su justificación, pero nunca de su existencia»[11]. Por eso, al ser el procedimiento cautelar sumario, sin la existencia de estación probatoria, menos la posibilidad de su actuación nace el presupuesto de verosimilitud del derecho. De allí que el profesor JUAN JOSÉ MONROY GÁLVEZ manifieste que precisamente, por aquella situación de urgencia, el actor tan sólo se limita a presentar una información sumaria respecto de las posibilidades de su posición frente al proceso[12.] Precisa, la razón de ser de la verosimilitud, llamado fumus boni iuris, es que requiere para la obtención de la medida cautelar sólo el "humo" de la existencia del derecho que solicita el demandante[13] .

42. La medida cautelar se concede al demandante o actor no porque ostente un derecho indiscutido y pleno sobre el objeto del proceso, sino, porque simplemente prima facie, es decir, preliminarmente su pretensión o derecho invocado parece amparable, situación que debe acreditarse con una prueba documental. No debe el juez perseguir la certeza, porque ella es el producto de una secuencia activa de verificaciones y deducciones lógicas que juegan armónicamente en un momento diferente del juicio. Al órgano jurisdiccional le basta y es suficiente la apariencia fundada del derecho, lo que equivale a responder asertivamente a la viabilidad jurídica de la pretensión, pero sin que ello signifique adelantar opinión alguna sobre el fondo del problema[14] . KIELMANOVICH destaca que en algunos casos la ley presume la verosimilitud del derecho, por las situaciones de las personas, la naturaleza de la pretensión o por el estado del proceso en el cual se pide, así cuando se trata de medidas cautelares a favor de quien obtuvo sentencia favorable[15] .

43. Atendiendo a lo expuesto, se debe verificar si existe una apariencia del derecho conforme ha argumentado el Consorcio. Sobre este punto, este Árbitro de Emergencia puede advertir que las controversias que el Consorcio pretende solicitar en el proceso arbitral principal que iniciará versaran sobre lo siguiente:

> *"**Primera pretensión principal***
> *Que el Árbitro de Emergencia DECLARE LA INEFICACIA de la Resolución del Contrato N° 466-2020-MDV/GM-UA, efectuada por la MUNICIPALIDAD*

[9] PODETTI, J. Ramiro. Tratado de las Medidas Cautelares. Tomo IV, Editorial Ediar, Buenos Aires 1956, p. 54
[10] BARONA VILAR, Silvia. Derecho Jurisdiccional II: proceso civil. Tirant Lo Blanch, Valencia 2008, p. 680
[11] PODETTI, J. Ramiro. Tratado de las Medidas Cautelares. Tomo IV, ob. Cit., p. 55-56.
[12] MONROY PALACIOS, Juan José. Bases para la formación de una Teoría Cautelar. Editorial Chavín, Comunidad, Lima 2002, p. 171.
[13] MONROY PALACIOS, Juan José. Bases para la formación de una Teoría Cautelar. Ob. Cit., p. 173-174
[14] HINOSTROZA, Alberto. El Embargo y Otras Medidas Cautelares. Editorial San Marcos, Lima 2002, p. 38.
[15] KIELMMANOVICK, Jorge. Medidas Cautelares. Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires 2000, p. 52.

DISTRITAL DE VINCHOS, comunicada mediante Carta Notarial N° 015-2022/MDV de fecha 15 de setiembre de 2022.

Segunda pretensión principal
Que, el Árbitro de Emergencia ORDENE a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS el pago de los reajustes contenidos en las valorizaciones de junio de 2021 a enero de 2022 que corresponden al monto de S/. 627,830.01 (seiscientos veinte siete mil ochocientos treinta con 01/100 soles), a FAVOR del CONSORCIO NAZARENO.

Tercera pretensión principal
Que el Árbitro de Emergencia ORDENE a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS asumir los gastos que irrogue la organización y tramitación del arbitraje, incluyendo los honorarios arbitrales, gastos administrativos, así como la asesoría técnica y legal".

44. Mediante dichas controversias, se advierte que el Consorcio busca que se deje sin efecto la resolución del Contrato N° 466-2020-MDV/GM-UA, efectuada por la Entidad, y comunicada mediante Carta Notarial N° 015-2022/MDV de fecha 15 de setiembre de 2022, dado que alega que no se cumplió con el procedimiento establecido en la normativa de contrataciones del Estado, y que verificada la culminación de la obra correspondía la conformación del Comité de Recepción del caso para la realización de las observaciones pertinentes y su respectiva subsanación, por lo que en postura del Consorcio no podría haber resolución por aplicación máxima de penalidades ya que ni siquiera se hubo conformado el Comité de Recepción que efectuará las observaciones sujetas a aplicación de penalidades; así como pretende que se le reconozcan pagos que la Entidad le adeudaría como consecuencia de la liquidación de obra a efectuarse.

45. En virtud a lo mencionado, el numeral 1 del Art. 164 del RLCE, establece lo siguiente:

" Artículo 164. Causas de resolución
164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:
*a) **<u>Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales</u>**, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;*
*b) **<u>Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades</u>**, en la ejecución de la prestación a su cargo; o*
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación
(…)" (El resaltado y subrayado es nuestro).

46. Sobre el particular, y de los medios probatorios aportados por el Consorcio se tiene que en efecto la Entidad resolvió el Contrato alegando la causal de acumulación máxima de penalidades, conforme se verifica directamente:

CARTA NOTARIAL N°015-2022/MDV

Vinchos, septiembre del 2021.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSORCIO NAZARENO.

Ing. CORDERO ZAMORA RUDDY RICHARD

Jr. Quijano Mendivil MZ D Lte 01 Ayacucho – Huamanga - Ayacucho.

CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es igual al documento que he tenido a la vista.

Lima: 30 NOV. 2022

Ricardo Fernandini Barreda
Notario de Lima

Presente. -

De mi mayor consideración:

La Municipalidad Distrital de Vinchos, por CONDUCTO NOTARIAL, le hace llegar la presente, para comunicarle que, visto el Informe N°2358-2022-MDV-UASA-LYA, se le comunica que el CONTRATO Nº466-2020-MDV/GM-UA, a la fecha adolece de aplicación de penalidades llegando a haber acumulado el **MÁXIMO DE PENALIDAD** por el incumplimiento de obligaciones al contrato precitado, ello en base al acta de verificación y constatación de obra, de fecha 07 de setiembre del 2022, en ese sentido bajo los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF, en su el Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato 165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En esios casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato (...), por tal razón se le comunica que notificada la presente queda resuelto el CONTRATO Nº466-2020-MDV/GM-UA, por las causales establecidas en el precitado informe y los antecedentes que forman parte integrante de la presente.

Es todo cuanto informo a su persona, para conocimiento y demás fines que corresponda.

Adjunto: Informe N°2358-2022-MDV-UASA-LYA, que va en 182 folios.

47. **Sin embargo, no se verifica cual es la justificación de la causal que ha invocado la Entidad exactamente, si es por acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o si es por otras penalidades o por ambas. Si bien la Carta Notarial se sustenta en un Informe No. 2358-2022-MDV-UASA-LYA, este no ha sido presentado al presente Árbitro de Emergencia para verificar cual ha sido la real justificación que ha tenido la Entidad para resolver el Contrato, es decir, si fue por acumulación del monto máximo de penalidad por mora, por otras penalidades o ambos**. Al menos de los medios probatorios que el Consorcio a presentado, se tendría una hipótesis razonable para fundamentar el hecho de que la resolución del contrato no pudo haber sido por acumulación máxima de penalidad por mora (retrasos), dado que conforme a los Asientos 726, 727, 728 y 729 del Cuaderno de Obra, la Obra habría culminado dentro del plazo estipulado contractualmente conforme se verifica:

Asiento N° 726 Del Residente de obra 19/05/22

Componente agua potable: tendido de Tub. HDPE 1", vaciado de dados de anclaje y empalme a Tub. PVC SAP de 1", culminación de levantamiento de pérdidas en cruce aéreo; colocación de llaves en válvulas de aire y purga. Finalmente limpieza general de las zonas afectadas desde captación hasta reservorio de Accopampa.

CONSORCIO NAZARENO

Ing. Rober [illegible] Cucho
CIP N° 82742
RESIDENTE DE OBRA

Ocurrencias: Siendo hoy último día del plazo de ejecución contractual y habiéndose culminado con la ejecución de metas y partidas del proyecto, solicito a la supervisión de obra, en virtud al artículo 208 del RLCE la verificación de los trabajos realizados y se pueda iniciar los trámites administrativos para la recepción de obra correspondiente.

CONSORCIO NAZARENO

Ing. Rober [illegible] Cucho
CIP N° 82742
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO NAZARENO

Ing. [illegible] Cucho

CONSORCIO VANCE

Ing. Bernic Tamis Barrón
CIP N° [illegible]
JEFE INGENIERO SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

19-05-2022 ASIENTO Nº 727 DEL SUPERVISOR DE OBRA

- Se ha realizado la verificación de los trabajos en obra en el SAP de Accopampa.

* En vista que se ha cumplido el plazo de ejecución de obra, la supervisión procederá a la verificación correspondiente y posterior pronunciamiento

CONSORCIO VANCE

Ing. Bernic Tamis Barrón
CIP N° [illegible]

24-05-2022 ASIENTO Nº 728 DEL SUPERVISOR DE OBRA

- En vista que se ha verificado los trabajos ejecutados en las diferentes comunidades, se debe precisar que el tiempo que indica el RLCE no es suficiente para la presente obra, pero si se puede indicar, que las metas se han cumplido de acuerdo al contrato principal y los adicionales de obra.
- Razón por la cual se procede a dar la conformidad de la culminación de obra, para lo cual la MDV debe conformar el comité de recepción de obra.

* Existen observaciones en los diferentes asientos de la supervisión, lo cual, el contratista debe subsanarlo.

CONSORCIO YANCE
Ing. Benk... Martínez
CIP. Nº 1[illegible]
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO NAZARENO

CONSORCIO YANCE

ENTIDAD EJECUTORA: _____

31-05-2022 ASIENTO N° 729 DEL SUPERVISOR DE OBRA

* Como ya se ha mencionado la obra ha culminado en los plazos establecidos.
* La obra en general ha llegado a tener los siguientes avances de obra de acuerdo a lo siguiente:
  - Porcentaje acumulado de acuerdo al contrato principal ejecutado es del 91.57%, el saldo por ejecutar corresponden a los deductivos vinculados en adicionales de obra.
  - Porcentaje acumulado ejecutado del Adicional de obra N° 03 es de 98.09%, el saldo por ejecutar corresponden a deductivos vinculantes y adicionales.
  - Porcentaje acumulado del Adicional de obra N° 04 ejecutado es del 100%.
  - Porcentaje acumulado ejecutado del Adicional de obra N° 05 es del 100%.
* Se espera la conformación del comité de recepción de obra.
* Hasta la fecha desde el mes de diciembre la MDV no paga por los servicios prestados.

CONSORCIO SANCE

48. En ese orden de ideas, parecería acreditadarse en un primer momento que existe verosimilud del derecho en el pedido del contratista, dado que no se desprende cual es en si la justificación del motivo por el cual la Entidad resolvio el Contrato, lo que pondría en tela de juicio la eficacia de la resolución efectuada por la Entidad, por lo que, la Entidad no tendría razón válida o causal para resolver el Contrato por aplicación máxima de penalidad por mora si se verifica que la obra culminó dentro del plazo. Asimismo, quedaría por verificar si la justificación de la resolución del contrato fue por la aplicación de otras penalidades, lo cual también se desconoce, pero en primer momento parecería evidenciarse una hipótesis razonable que quedaría evidenciada ante estos cuestionamientos lógicos que no permiten verificar cual es la justificación de la causa real por la que la Entidad le resolvió el Contrato al Consorcio, y en ese sentido, ***si se pone en tela de juicio la eficacia de la resolución del contrato, es claro que para ello tiene que continuar estando vigente la garantía de fiel cumplimiento del Contrato conforme al artículo 155º de la RLCE:***

> *"**Artículo 155. Ejecución de garantías***
> *155.1 Las garantías se ejecutan en los siguientes supuestos:*

(…)
b) ***La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta****, en su totalidad,* ***cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato.*** *En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado".*

49. ***Ahora, para que se pueda terminar de verificar la verosimilitud del derecho invocado de forma plena por parte del Consorcio, tendría que verificarse a su vez que el Consorcio aun mantenga el derecho para poder cuestionar la resolución del contrato***, es decir, que no haya dejado consentir la resolución del Contrato para llevar precisamente cuestiones vinculadas al mismo en vía conciliatoria y/o arbitral. Sin embargo, el mismo Consorcio precisa que la notificación de la resolución del Contrato les fue comunicada el 15 de septiembre de 2022 como se verifica de la prueba documental directamente.

La Municipalidad Distrital de Vinchos, por ... llegar la presente, para comunicarle que, visto el Informe N°2358-2022-MDV-UASA-LYA, se le comunica que el CONTRATO Nº466-2020-MDV/GM-UA, a la fecha adolece de aplicación de penalidades llegando a haber acumulado el **MÁXIMO DE PENALIDAD** por el incumplimiento de obligaciones al contrato precitado, ello en base al acta de verificación y constatación de obra, de fecha 07 de setiembre del 2022, en ese sentido bajo los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF, en su el Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato 165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato (...), por tal razón se le comunica que notificada la presente queda resuelto el CONTRATO Nº466-2020-MDV/GM-UA, por las causales establecidas en el precitado informe y los antecedentes que forman parte integrante de la presente.

Es todo cuanto informo a su persona, para conocimiento y demás fines que corresponda.

Adjunto: Informe N°2358-2022-MDV-UASA-LYA, que va en 182 folios.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS
RAÚL RAMOS CAYO

CERTIFICO, LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE PROCEDE DE Raúl Ramos Cayo CON DNI N° 42464324 QUIEN HA FIRMADO EN MI PRESENCIA, DE LO QUE DOY FE, REFERIDO AL ART.68 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. – LEY N°29824 JUSTICIA DE PAZ.

VINCHOS 15 septiembre 2022

15 SEP 2022
05:48 PM

50. Asimismo, el propio Contratista en su escrito de solicitud cautelar, reafirma que la resolución del Contrato les fue notificada el 15 de septiembre de 2022.

Sobre la resolución del contrato

7.2. Con fecha 15 de setiembre de 2022, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS comunica al CONSORCIO NAZARENA, la resolución del CONTRATO. Dicha comunicación fue efectuada mediante la Carta Notarial N° 015-2022/MDV.

Le mencionada resolución del CONTRATO tiene como causa la *acumulación máxima de penalidades.*

51. Conforme a ello se tiene que, el plazo de caducidad que tiene el Consorcio para cuestionar la resolución del Contrato se reduce al plazo reglamentario dispuesto en el artículo 166º, numeral 166.3 del RLCE que señala lo siguiente:

> *"**Artículo 166. Efectos de la resolución***
> *(…)*
> *166.3. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta **(30) días hábiles siguientes de notificada la resolución**. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida".*

52. En ese sentido, ***el Consorcio tenía desde el 16 de septiembre hasta el 27 de octubre para iniciar conciliación y/o arbitraje sobre la resolución del contrato efectuada por la Entidad***, sin embargo, de los medios probatorios aportados al presente Árbitro de Emergencia, no se verifica que el Consorcio haya iniciado conciliación y/o arbitraje en el plazo de caducidad reglamentario, dejando consentir con ello la resolución del contrato y en ese sentido, la Entidad al no verificar inicio de conciliación y/o arbitraje, procedió con solicitar la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento como se verifica a continuación:

RICARDO FERNANDINI BARREDA
- NOTARIO -
Av. Paseo de la República 3046 - San Isidro
FECHA: 30 NOV 2022
1425135
Carta Notarial N° .....

CARTA NOTARIAL

SEÑORES : **AVLA PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

DIRECCIÓN : Calle las Begonias N° 415, Edificio Torre Begonias piso 3 San Isidro

ASUNTO : Ejecución de Carta Fianza

REF. : Carta Fianza N° 3002020016728-4, emitida por AVLA Perú de fecha 03/10/2022.

FECHA : 29 de noviembre del 2022

Previo cordial saludo me dirijo a Usted, mediante la presente carta notarial en mi condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Vinchos, con la finalidad de realizar el requerimiento formal para la ejecución inmediata de la carta Fianza N° 3002020016728-4 por Garantía de Fiel Cumplimiento por el importe de s/. 1, 379,856.95 de la Adjudicación Simplificada- Decreto de Urgencia 114-2022- N° 001-2020-MDV/CS Primera Convocatoria para la Contratación de la Ejecución de la obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Creación de Unidades Básicas de Saneamiento en 16 localidades Rurales de la comunidad de Vinchos- Huamanga- Ayacucho. La ejecución obedece a la Aplicación de la Máxima Penalidad comunicada con carta notarial N° 015-2022/MDV, de fecha 15 de septiembre del 2022, el cual ha quedado consentida a la fecha ha quedado consentida por el incumplimiento a la relación contractual según contrato N° 466-2020- MDV/ GM- UA por parte del CONSORCIO NAZARENO, que se encuentra integrada por CHV Ingenieros Contratistas Generales SAC e Inversiones Molina &M EIRL.

Por lo expuesto, solicito dar cumplimiento al requerimiento de ejecución inmediata de la Carta Fianza en el plazo de 24 horas, en estricto cumplimiento de las normas aplicables a la materia, en caso de incumplimiento nos veremos en la imperiosa necesidad de informar a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a fin de que se tomen las acciones que corresponda.

Este documento no ha sido registrado en acta Notaria

53. Por todo lo señalado, y dado que el Consorcio dejó consentir la resolución del contrato, para el presente Árbitro de Emergencia, ***ya se ha perdido la verosimilitud en el derecho invocado, dado que las pretensiones cautelares están directamente vinculadas a la primera pretensión del futuro proceso arbitral*** conforme se detalla a continuación:

Primera pretensión principal (del futuro proceso arbitral)

"Que el Árbitro de Emergencia DECLARE LA INEFICACIA de la Resolución del Contrato N° 466-2020-MDV/GM-UA, efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, comunicada mediante Carta Notarial N° 015-2022/MDV de fecha 15 de setiembre de 2022"

Pretensiones cautelares solicitadas

"1. Que la Municipalidad Distrital de Vinchos se abstenga de ejecutar la Carta Fianza No. 3002020016728-4, emitida por AVLA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A por el importe de S/. 1´379,586.95 (Un Millón Trescientos

Setenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Seis con 95/100 soles) que garantiza el fiel cumplimiento del Contrato No. 466-2020-MDV/GM-UA.

2. Que AVLA Perú Compañía de Seguros S.A, se abstenga y/o rechace cualquier requerimiento y/o solicitud por parte de la Municipalidad Distrital de Vinchos destinada a ejecutar la Carta Fianza No. 3002020016728-4".

54. ***Ello es así por lo dispuesto en el artículo 155º del RLCE sobre ejecución de garantías, que señala que la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta en su totalidad cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato ha quedado consentida o se ha emitido un laudo arbitral que declare procedente la decisión de resolver el contrato (obviamente se entiende dentro del marco de un proceso arbitral iniciado dentro de sus plazos perentorios para llevar a arbitraje controversias vinculadas a la resolución del contrato).***

55. ***Por lo expuesto, se deja a salvo el derecho del Consorcio respecto de sus otras pretensiones (Segunda pretensión y Tercera pretensión) para que sean ventiladas en el proceso principal***, sin embargo, y en aras de propender a un análisis integral, se señalará brevemente si cabe la posibilidad de que estas pretensiones guarden vinculación con el petitorio cautelar antes visto para no dejar ningún cabo suelto a la posibilidad de otorgamiento de la cautelar.

56. Así se tiene que, lamentablemente se verifico que las demás pretensiones no coadyuvan a que la garantía de fiel cumplimiento no pueda ejecutarse por lo ya dispuesto en el artículo 155º del RLCE ***que dispone la ejecución total de la garantía de fiel cumplimiento ante el consentimiento de la resolución del contrato:***

Segunda pretensión principal
Que, el Árbitro de Emergencia ORDENE a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS el pago de los reajustes contenidos en las valorizaciones de junio de 2021 a enero de 2022 que corresponden al monto de S/. 627,830.01 (seiscientos veinte siete mil ochocientos treinta con 01/100 soles), a FAVOR del CONSORCIO NAZARENO.

Tercera pretensión principal
Que el Árbitro de Emergencia ORDENE a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS asumir los gastos que irrogue la organización y tramitación del arbitraje, incluyendo los honorarios arbitrales, gastos administrativos, así como la asesoría técnica y legal".

RESPECTO AL PELIGRO EN LA DEMORA

57. Respecto al requisito del peligro en la demora, éste es un presupuesto objetivo de la medida cautelar, el cual no sólo se constituye por la existencia de un peligro, sino que además es indispensable que dicho peligro sea inminente, por lo que, resulta necesario

e imprescindible expedir un remedio inmediato y eficaz, en tanto se tramita el proceso principal.

58. En efecto, Ottolengui, citado por Monroy Gálvez[16] en su obra "Temas de Proceso Civil" señala al respecto que "*Para aproximarse a una noción más clara del periculum in mora, no basta solamente que el interés de obrar nazca de un estado de peligro y que la medida solicitada tenga por ello la finalidad de prevenir un daño temido, sino que por el contrario es necesario que, a causa de esta inminencia de peligro, tal medida tenga carácter de urgencia, en cuanto sea de prever que, si la misma se demorase, se transformaría en daño efectivo o se agravaría el ya ocurrido; esto es, que la providencia cautelar debe ser dictada sin demora, de otro lado sería ineficaz".* Montero Rosas, haciendo referencia a Fairen Guillen afirma que "*el periculum in mora básico de las medidas cautelares, no es el peligro de daño genérico jurídico, al cual se atiende mediante los dos procesos clásico, sino el peligro específico derivado de la duración de la actividad jurisdiccional, considerada en sí misma como posible causa de un ulterior daño; mientras que el daño ya causado encuentra su remedio en los procesos declarativo y ejecutivo, las medidas cautelares tratan de evitar que ese daño se agrave como consecuencia de la duración de aquellos.*[17]

59. Así pues, este elemento significa que la medida cautelar sólo se justifica cuando tiene como propósito evitar un daño grave al derecho invocado por el solicitante de la medida cautelar y, en el presente caso, para este Árbitro de Emergencia, ya se ha perdido tal peligro en la demora, porque como efecto de que ya ha quedado consentida la resolución del contrato, la Entidad ya se habría encontrado facultada legalmente, conforme al artículo 155º del RLCE, para solicitar la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, tal como se desprende del medio probatorio analizado.

[16] MONROY GÁLVEZ, Juan. Tema de Proceso Civil. Ediciones Studium. Lima. Pág. 28.

[17] MONTERO AROCA, Juan. Trabajos de derecho procesal. Ed. Bosch. Barcelona, 1998. Pág. 608.

RICARDO FERNANDINI BARREDA
- NOTARIO -
Av. Paseo de la República 3046 - San Isidro
FECHA: 30 NOV 2022
1425135
Carta Notarial N° .....

CARTA NOTARIAL

SEÑORES : **AVLA PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

DIRECCIÓN : Calle las Begonias N° 415, Edificio Torre Begonias piso 3 San Isidro

ASUNTO : Ejecución de Carta Fianza

REF. : Carta Fianza N° 3002020016728-4, emitida por AVLA Perú de fecha 03/10/2022.

FECHA : 29 de noviembre del 2022

Previo cordial saludo me dirijo a Usted, mediante la presente carta notarial en mi condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Vinchos, con la finalidad de realizar el requerimiento formal para la ejecución inmediata de la carta Fianza N° 3002020016728-4 por Garantía de Fiel Cumplimiento por el importe de s/. 1, 379,856.95 de la Adjudicación Simplificada- Decreto de Urgencia 114-2022- N° 001-2020-MDV/CS Primera Convocatoria para la Contratación de la Ejecución de la obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Creación de Unidades Básicas de Saneamiento en 16 localidades Rurales de la comunidad de Vinchos- Huamanga- Ayacucho. La ejecución obedece a la Aplicación de la Máxima Penalidad comunicada con carta notarial N° 015-2022/MDV, de fecha 15 de septiembre del 2022, el cual ha quedado consentida a la fecha ha quedado consentida por el incumplimiento a la relación contractual según contrato N° 466-2020- MDV/ GM- UA por parte del CONSORCIO NAZARENO, que se encuentra integrada por CHV Ingenieros Contratistas Generales SAC e Inversiones Molina &M EIRL.

Por lo expuesto, solicito dar cumplimiento al requerimiento de ejecución inmediata de la Carta Fianza en el plazo de 24 horas, en estricto cumplimiento de las normas aplicables a la materia, en caso de incumplimiento nos veremos en la imperiosa necesidad de informar a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a fin de que se tomen las acciones que corresponda.

Este documento no ha sido registrado en esta Notaría

60. En atención a lo descrito previamente, el Árbitro de Emergencia, refrenda que el peligro en la demora ya se ha visto desfasado al estado actual de acontecimientos, ya que el Consorcio a solicitado arbitraje de emergencia con solicitud cautelar, cuando ya ha caducado la posibilidad de llevar a arbitraje la resolución del contrato, lo que ha ocasionadoa su vez que la Entidad haya tenido la justificación legal para solicitar la ejecución de la garantía (lo cual así hizo), ***hecho directamente vinculado al petitorio cautelar.***

RESPECTO A LA ADECUACIÓN Y RAZONABILIDAD

61. Respecto a la razonabilidad de la medida cautelar, en el caso que nos compete, el presente Árbitro de Emergencia estima necesario realizar un análisis de proporcionalidad a efectos de determinar la idoneidad de la medida cautelar vinculada a la pretensión principal a ser planteada por el Consorcio.

62. Este análisis de proporcionalidad busca que toda afectación de cualquier derecho sea equilibrada y razonable, es decir, que no sea inútil ni desproporcionada. Vale indicar que dicho análisis está fundamentado en el principio constitucional de proporcionalidad, cuyo objeto es establecer una correcta relación de preferencia (o precedencia) condicionada entre los principios o derechos en conflicto, reduciendo de los márgenes de discrecionalidad.

63. Aunado a lo anterior se debe tener en cuenta que en una medida cautelar debe haber **PROPORCIONALIDAD** entre el pedido y la situación jurídica o fáctica que es objeto de la aseguración. Así el doctor Walter Eduardo Campos Murillo indica que:

> *"(…) a fin de conceder la medida solicitada debe evaluar que el pedido cumpla con los tres requisitos, esto es que existe verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y que la medida solicitada resulte adecuada con la naturaleza de la pretensión principal, solo en este caso estará en aptitud de conceder la medida. Ocurre, sin embargo, que la ley da un tratamiento distinto al tercer requisito, pues si bien la carencia de alguno de los dos primeros requisitos determina el rechazo de la solicitud cautelar, respecto del tercero, la adecuación, la norma permite que su insuficiencia sea "subsanada" por el juez, de manera que, en definitiva, se cumpla también con ese tercer presupuesto para la concesión de la medida cautelar"*[18].

64. Adicionalmente, tal como lo señala el doctor Plasencia Cruz, Jorge Antonio[19], *"la adecuación de la medida cautelar se refiere de un lado, a la congruencia y conexidad que debe haber entre la pretensión cautelar y la pretensión principal que se quiere cautelar y, de otro, a la proporcionalidad que ha de existir entre la medida cautelar que pudiera concederse y la pretensión principal. De ese modo, se evita que se concedan medidas cautelares en exceso, sino únicamente las necesarias para cautelar de manera suficiente la pretensión principal. Es precisamente en este presupuesto que* ***la incidencia del principio de la buena fe*** *cobra especial relevancia en los sujetos partícipes del proceso, a efectos de otorgar la medida cautelar* ***"pertinente****. (el subrayado es nuestro)*

65. En ese sentido, el Árbitro de Emergencia advierte que los derechos en conflicto en este caso son, por un lado, el derecho del Consorcio de que se declare la ineficacia de la resolución del Contrato; y, por otro lado, se encuentra el derecho de la Entidad de resolver el contrato y de ejecutar la garantía de fiel cumplimiento como consecuencia de ello.

66. En ese sentido, para evaluar la razonabilidad, congruencia y proporcionalidad, el Árbitro de Emergencia tomará en consideración la pretensión que se discutirá en el arbitraje principal.

---

[18] Campos Murillo, W. *"La adecuación en las medidas cautelares"*. Recuperado el 12 de abril de: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2eeb708043eb964c9426f40365e6754e/Adecuacion_medidas_cautelares_Walter_Eduardo_Campos_Murillo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2eeb708043eb964c9426f40365e6754e

[19] Plascencia Cruz, Jorge. La Buena Fe en el Proceso Cautelar; Derecho y Cambio Social. https://www.derechoycambiosocial.com/revista013/buena%20fe%20en%20el%20proceso%20cautelar.htm

67. En ese orden de ideas, en el presente caso, y al evaluar la verosimilitud del derecho se llegó a determinar que ***el Consorcio tenía desde el 16 de septiembre hasta el 27 de octubre para iniciar conciliación y/o arbitraje sobre la resolución del contrato efectuada por la Entidad***, sin embargo, de los medios probatorios aportados al presente Árbitro de Emergencia, no se verificó que el Consorcio haya iniciado conciliación y/o arbitraje en el plazo de caducidad reglamentario, dejando consentir con ello la resolución del contrato y en ese sentido, la Entidad al no verificar inicio de conciliación y/o arbitraje, procedió con solicitar la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

68. En tal sentido, ya no existe razonabilidad y proporcionalidad en el pedido del Consorcio dado que se ha visto desfasado por haber dejado consentir la resolución del Contrato conforme al plazo de caducidad previsto en la normativa de contrataciones, hecho ***directamente vinculado al petitorio cautelar.***

RESPECTO A LA CONTRACAUTELA

69. Finalmente, la contracautela opera como una garantía por la realización de la medida cautelar, fundada en el principio de igualdad pues debe preverse la posibilidad de asegurar al demandado la efectividad del resarcimiento de los daños generados por la medida cautelar[20].

70. Sin perjuicio de ello, el Árbitro de Emergencia tiene en consideración que la contracautela consiste en una caución que presta el solicitante de la medida cautelar para garantizar el resarcimiento de cualquier perjuicio ilícito que pudiera sufrir el afectado de la medida cautelar como consecuencia de su ejecución.

71. El Árbitro de Emergencia ha señalado que la concurrencia de: (i) la verosimilitud del derecho invocado, (ii) la existencia de peligro en la demora y (iii) la razonabilidad de la medida cautelar, se analizan para determinar si corresponde otorgar o no una medida cautelar, es decir, su procedencia; mientras que la contracautela se analiza para determinar si una medida cautelar deba ser ejecutada.

72. En la misma línea, PEYRANO señala que la prestación de la contracautela no es un requisito para su procedencia, sino solo un presupuesto para que resulte viable su ejecución.[21]

73. Ahora bien, dadas las circunstancias anotadas precedentemente, en el presente caso, ***como no se pudieron verificar los elementos principales para el otorgamiento de la cautelar, el presente Árbitro de Emergencia no tiene mayor pronunciamiento que realizar respecto a la contracautela.***

[20] Ledesma Narváez, Marianella. (2016) "Las Medidas Cautelares en el Proceso Civil". Pág. 33.
[21] PEYRANO, Jorge W. *Compendio de reglas procesales en lo civil y comercial*. Segunda Edición. Rosario: Zeus, p. 82.

74. Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, el Árbitro de Emergencia considera que corresponde declarar **INFUNDADA** la solicitud de medida cautelar de no innovar peticionada por el Consorcio; sin perjuicio de que según sea el desarrollo de las actuaciones arbitrales aquél pueda ser modificado o revisado a petición de cualquiera de las partes ante el Tribunal Arbitral o Árbitro Único que se instale de así considerarlo pertinente.

III. DECISIÓN

Por tales consideraciones expuestas, el Árbitro de Emergencia **RESUELVE**:

PRIMERO: Dejar constancia que la Entidad no cumplió con absolver el traslado conferido mediante la Decisión No. 1 de fecha 02 de diciembre de 2022.

SEGUNDO: Declarar **INFUNDADA** la solicitud de medida cautelar de no innovar peticionada por el Consorcio Nazareno.

TERCERO: Precisar que se deja a salvo el derecho que tiene el Consorcio respecto de la Segunda y la Tercera pretensión del futuro proceso arbitral.

Daniel Triveño Daza
Árbitro de Emergencia